

1501555-53.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... o acusado admitiu a realização do tráfico de drogas, dizendo que estava passando por dificuldades. Consignou que o local dos fatos era bastante conhecido pela realização do tráfico de drogas. Disse que não conhecia o réu anteriormente aos fatos, sendo aquela a primeira vez que o abordou. Esclareceu que a campana foi realizada de dentro da viatura, a cerca de 40 a 50 metros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501555-53.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501555-53.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRANDON DA SILVA MARTINS

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

BRANDON DA SILVA MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na inicial, em ocasião de calamidade pública, tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 18 porções de maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica. Foi também apreendido com o réu a quantia de R\$10,00.

O réu foi notificado e ofereceu defesa preliminar. Recebida a denúncia, foi o réu citado.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e, ao final, foi o réu interrogado.

Realizados os debates, o Ministério Público pediu a procedência da ação para a

condenação do réu, nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Formulou pedidos relativos à fixação da pena e do regime prisional.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime para a conduta de porte de entorpecente para consumo pessoal. Requereu a fixação da pena-base em seu mínimo legal, bem como o afastamento da circunstância agravante relativa à calamidade pública, pugnando, por fim, pela fixação de regime prisional diverso do fechado. É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação, pelo laudo pericial, bem como pelo conjunto probatório constante dos autos.

Também não restam dúvidas quanto à autoria do delito.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do crime descrito na denúncia.

Disse ser usuário de maconha e alegou ter ido ao local dos fatos para comprar droga. Contou que não chegou a adquirir o entorpecente antes de ser abordado, tendo sido encontrado somente dinheiro em seu poder. Disse que estava com o valor de apenas dez reais em seu bolso e, caso fosse o traficante, estaria com mais dinheiro. Contou que o indivíduo que traficava saiu do local e não foi abordado pelos policiais. Alegou que também se deslocou, de bicicleta, para baixo de uma ponte, onde foi abordado. Disse que os policiais encontraram os entorpecentes e lhe atribuíram a propriedade deles. Alegou que não viu os policiais encontrando as drogas e que estas somente lhe foram mostradas quando estava na viatura. Não conhecia os policiais que o abordaram.

Contudo, a negativa do réu e a versão por ele fornecida não encontram respaldo nos demais elementos de prova constantes dos autos.

A testemunha policial civil Raphael Ramos Jacovani, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que realizava ronda com seu parceiro e ao passarem por um local já conhecido como ponto de venda de drogas, no canal, avistaram o réu em atitude suspeita. Declarou que estavam em viatura descaracterizada e a estacionaram mais adiante, a fim de realizar campana. Disse que, passados cerca de 15 a 20 minutos, viram o acusado ser procurado por um rapaz, que trocou algo com ele. Narrou que o acusado foi, então, à beira do canal, em uma calçada onde havia mato e entulho, e, de baixo de uma madeira, retirou um filete de maconha. Relatou que o réu retornou ao rapaz que o aguardava, entregou a ele o filete de maconha, e aquele se retirou do local. Disse que o réu se afastou um pouco do ponto de onde havia retirado a droga e, então, realizou-se a abordagem. Narrou que o policial Paulo efetuou a busca pessoal e, com o réu, encontrou dez reais. Realizada busca no local onde o acusado havia abaixado e pegado a droga, foram encontrados 18 filetes de maconha. Declarou que, informalmente, o acusado admitiu a realização do tráfico de drogas, dizendo que estava passando por dificuldades. Consignou que o local dos fatos era bastante conhecido pela realização do tráfico de drogas. Disse que não conhecia o réu anteriormente aos fatos, sendo aquela a primeira vez que o abordou. Esclareceu que a campana foi realizada de dentro da viatura, a cerca de 40 a 50 metros do local onde estava o réu, e ocorreu no horário do almoço, entre meio-dia a uma hora da tarde. Afirmou que foi possível ver a troca de objetos ocorrida, com o acusado recebendo dinheiro e entregando a maconha ao indivíduo que o aguardava, pois o policial Paulo utilizou binóculos para a diligência.

No mesmo sentido, a testemunha policial civil Paulo Sergio Pereira de Menezes, ouvida em Juízo, narrou que realizava diligência em viatura descaracterizada com o policial Raphael quando, ao passarem pelo local dos fatos, conhecido pela venda de entorpecentes, visualizaram o acusado, em atitude suspeita, e decidiram monitorá-lo. Narrou que, com a viatura já estacionada, passados alguns minutos, viram um indivíduo aproximar-se do réu, conversar com ele e entregar dinheiro a ele.

Declarou que o acusado pediu que aquele indivíduo o aguardasse e caminhou até a beira do canal, onde agachou-se, levantou um pedaço de madeira e de lá retirou um filete de maconha. Esclareceu que foi possível, com o uso de binóculos, ver qual foi a droga que o acusado buscou naquele local. Relatou que o acusado retornou e entregou a droga ao indivíduo que o aguardava, tendo este se retirado do local em

seguida. Disse que o réu caminhou em sentido à ponte, onde foi, então, abordado. Realizada a busca pessoal, com o réu foi encontrado o dinheiro que ele havia acabado de receber e, em busca no local onde estava a droga, lá foram encontrados 18 filetes de maconha. Relatou que o acusado admitiu, informalmente, a propriedade da droga e a prática do crime, dizendo que estava precisando de dinheiro. Não conhecia o réu anteriormente aos fatos, tendo sido aquela a primeira vez que o abordou.

Não há dúvidas, portanto, sobre a conduta criminosa do acusado, no que se refere ao tráfico de drogas, diante das provas produzidas.

Ressalta-se a palavra dos policiais civis, que de maneira segura, uniforme e convincente, descreveram com detalhes como ocorreu a abordagem do acusado e a apreensão da droga.

Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade dos testemunhos dos policiais.

Como já se decidiu "é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando ele fosse convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor, aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade" (Apelação criminal nº 112.195-3/1, Santos, Rel. Des. Canguçu de Almeida, em 07/10/1991, 2ª Câmara Criminal).

Aliás, mostra-se "imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que o depoimento de policiais responsáveis pela segurança pública, não podem ser desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem função de salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumprir a contento" (TJSP - AP - Rel. Walter Guilherme - j. 10.03.98 - JTJ 214/284).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de manifestar-se favoravelmente à validade desses depoimentos. A propósito, registro: "Tóxicos - Tráfico - Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente" (STF - 2ª T. - HC nº 74.522-9/AC - Rel. Mm. Maurício Correa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1ª Turma - HC nº 74.608-0/SP - Rel. Mm. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO INCORRETO. MENORIDADE

RELATIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO À MÍNGUA DE PEDIDO NO RECURSO MINISTERIAL. REGIME FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada em poder do réu.

2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10).

3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG – Pleno – Voto Min. Cezar Peluso – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG – Pleno – Voto Min. Luiz Fux – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 838/842).

4. Dosimetria da pena estabelecida de modo incorreto. Menoridade relativa. Correção de ofício.

5. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 121.057/SP – Rel. Min. Luiz Fux – j. 25.02.14 – DJU 18.03.14; HC 118.380/SP – Rel. Min. Teori Zavaski – j. 04.02.14 – DJU 14.02.14; HC 116.541/ES – Rel. Min. Gilmar Mendes – j. 21.05.2013 – DJE 06.06.13; HC 109.236/SP – Rel. Min. Cármen Lúcia – j. 13.12.11 – DJU 14.23.12). Manutenção à míngua de pedido no recurso Ministerial.

6. O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes

hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

7. Provimento do recurso do Ministério Público e correção, "ex officio", da dosimetria da pena." (Ap. nº 3003382-41.2013.8.26.0471; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Porto Feliz; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 01/06/2016; Data de registro: 07/06/2016) (grifo nosso)

"Tráfico de entorpecentes - Agente que mantém em depósito e guarda substância estupefaciente - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda - Caracterização

Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e de "guardar".

Tráfico de entorpecentes - Agente que vende substância estupefaciente a policial pensando tratar-se de consumidor - Apreensão que quantidade expressiva de entorpecente por ele guardado - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com o conjunto probatório e com a quantidade de entorpecente apreendida

Realiza o tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 o agente que vende substância estupefaciente a policial, pensando tratar-se de consumidor. Ainda que assim não fosse, o próprio estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente não é necessário para caracterizar o tráfico, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e "guardar". A ulterior alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio não se coaduna com a dinâmica de sua apreensão, devendo ser afastada.

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena - Tráfico de Entorpecentes - Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido - Admissibilidade

Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na variedade e qualidade do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

Cálculo da Pena - Tráfico de entorpecentes - Desnecessidade de comprovação de nexos causal entre a conduta do acusado e a circunstância da apreensão ter ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino - Causa de aumento de pena (art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) de natureza objetiva - Reconhecimento

Imperioso o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 sempre que for constatado que o tráfico de drogas estava sendo praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Em tal situação, torna-se dispensável a comprovação de que o acusado comercializava entorpecentes erigindo diretamente os alunos da escola como público alvo, uma vez cuidar-se de causa de aumento de natureza objetiva." (Ap. nº 0039706-12.2014.8.26.0224; Relator(a): Grassi Neto; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 19/05/2016; Data de registro: 19/05/2016) (grifo nosso)

Apenas para consignar, o esforço da Defesa em desqualificar os depoimentos das testemunhas policiais não é suficiente para retirar a força probante deles. Frise-se que os depoimentos das testemunhas, colhidos durante a instrução criminal, mostram-se coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias em que se deu a

abordagem do réu e a localização dos entorpecentes, além de estarem em verdadeira consonância com suas declarações prestadas à Autoridade Policial.

Ambas as testemunhas afirmaram ter visto o acusado no local já conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas e asseveraram tê-lo visto sendo procurado por um terceiro indivíduo, que entregou dinheiro a ele.

Narraram que viram o réu deslocar-se até um local próximo ao canal, onde abaixou-se e retirou, de baixo de uma madeira, um filete de maconha, entregando-o, em seguida, ao indivíduo que o aguardava.

Consignaram que, para a campana, foi feito uso de binóculos, tendo sido possível visualizar que o réu recebeu dinheiro do indivíduo que dele se aproximou e, após, entregou àquele um filete de maconha.

Acrescentou a testemunha policial Paulo Sérgio que, ao realizar a busca pessoal no acusado, encontrou em seu poder a quantia de dez reais, que ele havia acabado de receber do indivíduo que dele havia se aproximado.

Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, não há dúvidas de que era o acusado que tinha as drogas em depósito, bem como não há qualquer dúvida de que o réu era o indivíduo que estava realizando o tráfico de drogas no local dos fatos.

De outro lado, nenhuma testemunha arrolada exclusivamente pela Defesa foi trazida em Juízo para ser ouvida, a fim de esclarecer os fatos ou, ao menos, contrariar concretamente a versão apresentada pelas testemunhas policiais civis.

Assim, a negativa do réu e a versão por ele apresentada não se mostraram críveis e restaram absolutamente isoladas do contexto probatório, devendo-se considerar os demais elementos de convicção existentes e produzidos durante o processo.

Na hipótese, seria mesmo um contrassenso pretender que a versão fornecida pelo acusado sobreponha-se aos depoimentos dos agentes de segurança encarregados de sua prisão, depoimentos estes que estão em harmonia com as demais circunstâncias que envolvem o delito.

Em outras palavras, impossível seria desmerecer os depoimentos dos policiais civis, pois são absolutamente aptos e suficientes para embasarem a inequívoca conclusão de que o réu é de fato traficante.

No presente caso os elementos de convicção são contundentes, seja em virtude da quantidade das drogas apreendidas, seja pela ação da equipe de policiais, tudo aliado à negativa isolada do réu.

Apenas para consignar, não há nada nos autos que pudesse justificar a conclusão de que o réu estaria sendo acusado injustamente da prática do delito de tráfico de drogas.

Dessa forma, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado, evidencia-se, pois, a realização do tráfico por ele.

Em arremate, a intenção mercantilista do acusado deriva da quantidade de drogas e demais circunstâncias em que o entorpecente e o dinheiro foram apreendidos. De mais a mais, "para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc." (TJRJ - AC 1.327/92 - Rel. Adolphino A. Ribeiro - RDTJRJ 20/310).

Provadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, considerando-se a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da prisão, a condenação do réu é medida que se impõe.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

Atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado não é portador de maus antecedentes e não há outras razões para a elevação de sua pena-base acima do mínimo legal, que fixa fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico que o réu é reincidente pela prática de mesma espécie de delito, conforme certidão criminal de fls. 17/18, motivo pelo qual aumento sua pena em 1/3, a qual resta fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor já estabelecido.

Sobre o aumento:

"PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/3 NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A reprimenda imposta ao paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador, sendo a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da natureza, quantidade e variedade das drogas. Precedentes. 3. Possibilidade de agravamento da pena em 1/3, na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência específica. 4. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HABEAS CORPUS HC 305029 SP 2014/0244748-0 (STJ). 5ª T. Rel. Min. GURGEL DE FARIA. Julg. 25/11/2014. Public. 03/12/2014)

Verifico, ainda, que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública.

Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública.

Ressalte-se que, segundo o artigo 61 do Código Penal, dentre as circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime, têm-se:

"j) em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido;" (grifei)

Inicialmente, observa-se que o dispositivo penal é expresso em determinar que a hipótese de agravante é qualquer calamidade pública, não havendo nenhum tipo de restrição no sentido de que somente calamidades públicas no âmbito federal caracterizariam a agravante.

De outro lado, não se nega que Municípios e Estados da Federação também têm a competência de editar decretos reconhecendo-se o estado de calamidade pública.

Assim, feita esta primeira observação, verifica-se que se está diante de normal penal em branco, cujo conceito é trazido por Luiz Régis Prado:

A lei ou norma penal em branco pode ser conceituada como aquela em que a descrição da conduta punível se mostra lacunosa ou incompleta, necessitando de outro dispositivo legal para sua integração ou complementação. Essa afirmação significa dizer que o preceito, hipótese legal (preceito ou prótase) é formulada de maneira genérica ou indeterminada, devendo ser preenchida colmatada ou determinada por ato outro normativo (legislativo ou administrativo) em regra, de cunho extrapenal, que fica pertencendo, para todos os efeitos, à lei penal. [...]. (PRADO, L. R. Curso de Direito Penal Brasileiro. Parte geral. V.1. São Paulo: RT, 2010.)

A norma penal em branco será heterogênea quando o complemento é oriundo de fonte diferente da que editou a norma principal.

Heleno Cláudio Fragoso define a norma penal em branco heterogênea como sendo uma descrição da conduta incriminadora do direito penal que necessita ser complementada por outra norma já existente ou futura, mas de fonte legislativa diversa.

Portanto, admite-se que o complemento das normas penais em branco heterogêneas, podem advir de fonte diversa da União e por órgão distinto do poder legislativo, ou seja, do Poder Executivo Estadual ou Poder Executivo Municipal. (FRAGOSO, H. C. Lições de Direito Penal (parte geral). 16.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.)

Segundo Nelson Hungria, os regulamentos, portarias ou editais integram a norma penal, pois com ela passam a fazer corpo ou unidade lógica.

Trata-se de um caso típico de lei penal em branco: seu complemento são as eventuais determinações do poder público (mediante editais ou portarias, oficialmente publicadas para o conhecimento geral) concernentes a medidas preventivas contra a incursão ou difusão de moléstia contagiosa (isto é, transmissível por contágio).

Tais medidas poderão ter, ou não, base em regulamento permanente. Poder público quer dizer, aqui, autoridade competente (federal, estadual ou municipal). (Comentários ao Código Penal, 5. ed., Rio de Janeiro, Forense, 1977, v. 1, t. 1, ps.102, n. 7. 66)

Portanto, pode o complemento da lei penal em branco ser elaborado por autoridades municipais e estaduais, apesar de só a União poder legislar sobre Direito Penal, tratando-se excepcionalidade somente essa complementação por órgão outro que não aquela.

Nesse sentido é o entendimento doutrinário:

“Quando se tratar de normas penais em branco heterogêneas, frise-se que “se utilizam de fontes formais heterogêneas, porque o órgão legislante é diverso. Como exemplo ilustrativo podemos indicar o crime contra a economia popular, referente à transgressão da tabela de preços, que é fixada por órgão do Poder

Executivo, através de regulamento federal, leis ou regulamentos estaduais ou municipais, tem como complemento da lei penal em branco um complemento de diferente fonte normativa” (Nucci, Guilherme de Souza, editora RT, 2. ed., 2002)

“É a determinação do poder público. O “poder público” que baixa a determinação pode ser qualquer autoridade (federal, estadual, distrital ou municipal) competente para o ato, a qual deve constar do rol de suas atribuições legais. Cuida-se, portanto, de lei penal em branco, pois seu preceito primário depende de complementação, a qual pode ser veiculada por outra lei (lei penal em branco homogênea ou lato sensu) ou por algum ato administrativo (lei penal em branco heterogênea ou stricto sensu)”. (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Especial (arts. 121 a 212) – Volume 2. 12ª edição. São Paulo: Editora Método, 2019, p.11.)

Conclui-se que Estados e Municípios têm competência para editarem o complemento de normas em branco heterogêneas, não se podendo falar em violação ao princípio da legalidade, pois a fonte legislativa diversa apenas complementa os elementos da tipicidade formal já indicados pela lei federal.

Finalmente, a agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime.

Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal. A pena deve ser acrescida de 1/6, ficando fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor já estipulado.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de aumento de pena a serem reconhecidas e não se pode reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante da reincidência específica do acusado. Com efeito, não caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem a utilização dos maus antecedentes ou reincidência para o aumento da pena nas primeiras fases da dosimetria e, ainda, suas considerações para fins de afastamento da redutora prevista na Lei de Drogas, posto que tal conjuntura, na primeira e segunda em relação à terceira etapa de dosagem das penas, possui natureza jurídica diversa.

Neste sentido, já decidiu o Pretório Excelso, confira-se:

“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DROGAS. PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DA DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA/MAUS ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO.

IDONEIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o magistrado sentenciante considerou os maus antecedentes ostentados pelo réu e a natureza altamente nociva da droga apreendida, de modo que a reprimenda não merece nenhum reparo nesse ponto. II Não procede a alegação de que a inexistência de certidão cartorária atestando o trânsito em julgado de eventual condenação inviabilizaria o reconhecimento de maus antecedentes/reincidência e que a folha de antecedentes criminais não serviria para esse fim. Esta Corte já firmou entendimento no sentido da idoneidade do referido

documento, que possui fé pública. Precedentes. III Infração cometida em transporte público. Incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006. IV Não caracteriza bis in idem a consideração da reincidência para fins de majoração da pena-base e como fundamento para a negativa de concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. V- Para a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, é necessário que o réu seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. VI Réu que apresenta maus antecedentes, condição que impede a aplicação da referida causa de diminuição. VII - Ordem denegada. (HC 107274, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 12/04/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 19-04-2011 PUBLIC 25-04-2011 LEXSTF v. 33, n. 388, 2011, p. 367-376).

Ainda no mesmo sentido:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS. INDEFERIMENTO DA MINORANTE JUSTIFICADO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. "1. Constatando-se que a paciente ostenta maus antecedentes, ausente ilegalidade na não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, haja vista o não preenchimento de exigência determinada nesta regra. "2. As circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante da agente, somadas à quantidade e à natureza da substância entorpecente apreendida em seu poder - mais de 3 quilos de maconha -, ademais, levaram à conclusão de que não se tratava de traficante ocasional, dedicando-se a atividade criminosa..." (STJ HC 230.835/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 21/09/2012).

Torno essa pena definitiva na ausência de outras modificadoras.

Considerando as peculiaridades do presente caso e as condições previstas no artigo 59 do Código Penal, cuidando-se de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, cujo aspecto altamente nocivo à sociedade em geral ninguém desconhece, por certo que não se afigura socialmente adequada e recomendável à situação a aplicação de penas alternativas ou outros benefícios que, por sinal, implicaria sensação de impunidade e incentivo à prática delituosa, frustrando-se a expectativa social, que exige e espera, em tais condições, efetiva e eficaz resposta à criminalidade cada vez mais crescente, além de ser o réu reincidente específico, motivos pelos quais fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena.

Não estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa por liberdade por restritiva de direitos. Também incabível o sursis.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige - Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante - Regime fechado justificado - Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito - Detração - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais - Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-

97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei)
Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu BRANDON DA SILVA MARTINS, qualificado nos autos, às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.
Nego ao réu o direito de apelar desta em liberdade, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, considerando-se os malefícios inerentes ao tráfico de drogas ao meio social, além de ser o acusado reincidente específico. A reiteração de condutas criminosas evidencia a dificuldade do réu em aceitar a ordem legal estabelecida, pois não hesita em reiterar a prática delitiva, colocando em maior risco a ordem social.
Finalmente, não há qualquer alteração da situação fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão que decretou a custódia cautelar no presente feito, mormente no momento em que foi proclamado culpado em primeiro grau de jurisdição. Portanto, verifico que ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo de rigor manter a prisão preventiva, cumprindo-se, outrossim, o disposto no parágrafo único do artigo 316 do mesmo diploma legal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.
Decreto o perdimento do valor apreendido nos autos em favor da União, com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06.
Custas na forma da lei.
P.R.I.C.
São Vicente, 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA